

1504207-65.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1504207-65.2020.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504207-65.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2050835/2020 - 02º D.P. BOM RETIRO, 10177512 - 02º D.P. BOM RETIRO, 943/20/102 -

02º D.P. BOM RETIRO, 2050835 - 02º D.P. BOM RETIRO, 943/20/102 - 02º D.P. BOM

RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATHAN KENNEDY SANTOS DE ARRUDA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

JONATHAN KENNEDY SANTOS DE ARRUDA, qualificado a fls. 13, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

Ele teria, No dia 21 de fevereiro de 2020, por volta das 16h43min, no Viaduto Santa Efigênia, República, nesta Capital, foi preso em flagrante quando trazia consigo, para venda a terceiros, sem autorização legal ou regulamentar: 17,3g (dezessete gramas e três decigramas) de Cannabis sativa L, conhecida como "maconha", erva que contém a substância Tetrahydrocannabinol, dividida em 33 cigarros; e 6,5g (seis gramas e cinco decigramas) de Cannabis sativa L, conhecida como "maconha", erva que contém a substância Tetrahydrocannabinol, na forma de um tablete.

Notificado o réu (fls. 60), ele apresentou a defesa prévia (fls. 54/59). Inviável a absolvição sumária, foi recebida a denúncia e designada a audiência de instrução e julgamento (fls. 66/67).

Encontram-se nos autos o auto de prisão em flagrante (fls. 4), o boletim de ocorrência (fls. 9/11), o auto de exibição e apreensão (fls. 12), o laudo de constatação preliminar (fls. 19/22) e o definitivo (fls. 96/98).

No dia de hoje, realizada a audiência de Instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelo Ministério Público e o réu interrogado ao final.

Ouvidas as partes, a acusação pleiteou a condenação do acusado nos termos da denuncia, contudo, concordou com a aplicação do trafico privilegiado, com a redução máxima da pena.

A Defesa pleiteou a absolvição pela falta de prova consubstanciada na inconsistência dos depoimentos prestados pelos policiais bem como porque ambos não foram capazes de reconhecer o réu. Alternativamente, pugnou pela aplicação do trafico privilegiado com a redução máxima da pena e fixação de regime aberto.

É o relatório.

Decido.

É procedente a ação penal porque, ao cabo da instrução criminal restou perfeitamente delineada a autoria e a materialidade do crime tipificado pelo artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 conforme mais adiante se verá.

Com efeito, a materialidade delitiva foi aferida pelo teor do auto de exibição e apreensão (fls.12) e dos laudos de constatação provisória (fls.19/22), bem como pelo laudo toxicológico definitivo de substancia entorpecente (fls. 96/98), com resultados positivos TETRAHIDOCANNABINOL (THC).

A autoria do delito, por seu turno, foi evidenciada pelo conjunto da prova oral colhida no curso da ação penal e pelos demais informes colhidos na fase inquisitiva, pesem os argumentos trazidos pela defesa.

Em regular instrução, os dois policiais que participaram da prisão do acusado foram ouvidos e de forma idônea e objetiva, contaram o que ocorreu.

Deixaram claro que não tinham condições de reconhecer o réu, presente em audiência, em razão do tempo decorrido entre o fato e a audiência realizada no dia de hoje.

Este fato bem demonstra a isenção de ambos.

Contudo, ambos foram capazes de se recordar da ocorrência.

Com efeito, o policial Alan não se recordou da fisionomia do acusado mas recordou-se da ocorrência. Estava em policiamento a pé quando visualizou uma pessoa com atitude suspeita, ele tentou desviar o olhar e demonstrou um certo nervosismo com a presença da polícia. Ele não tentou fugir e foi abordado. Com ele foi encontrado maconha já embalada em forma de cigarro, em uma quantidade que não era apenas para uso. Além disso, um tablete de maconha foi localizado. Ele não quis falar sobre a apreensão. Não havia dinheiro com ele. A maconha foi localizada na cintura. Não trabalhava na região então não saberia dizer se ali é comum o trafico. Ele estava sozinho no momento da abordagem. Foi abordado no viaduto. Foi o parceiro quem encontrou a droga porque foi ele quem fez a revista pessoal.

Já o policial Felipe, por sua vez, não se recordou da fisionomia do acusado mas, sobre os fatos, recordou-se que estava em atividade delegada com o companheiro.

Estavam patrulhando sobre o viaduto e observou Jonathan andando que, ao perceber a presença policial, demonstrou certo nervosismo. Resolveram abordar. Ele não tentou fugir. Encontrou cerca de 30 (trinta) cigarros de maconha, já prontos para uso, e um tablete para fazer esses cigarros. Não havia dinheiro com ele. Ele nada afirmou sobre o entorpecente. Foi conduzido ao DP. Foi o depoente quem fez a revista.

Estavam a pé. Ele estava sozinho naquele momento e caminhava no viaduto. Constatado o entorpecente, pediu apoio de viatura e foram todos ao DP.

Como se vê, o quadro probatório é sólido e não deixa dúvidas acerca da conduta delituosa do acusado. Os elementos de convicção colhidos na fase policial e em juízo revelam-se firmes e substanciais, apontando-o com segurança como agente criminoso, no caso vertente.

É sabido que no processo penal por tráfico normalmente a prova acusatória consubstancia-se em depoimentos de policiais, civis ou militares, que efetivam a

apreensão da droga. E presume-se regular a atuação de agentes públicos investidos no cargo para segurança de todos, pois seria paradoxal que o Estado atribuisse a uma pessoa a execução do ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas desmerecesse sua palavra.

É o raciocínio que mais se coaduna com a realidade das coisas, aplicado na jurisprudência em geral, tanto no Superior Tribunal de Justiça (REsp 151.150-SC, Rel.Min. José Dantas, j. 7.4.98) como no Supremo Tribunal Federal (HC 74.608-0-SP, Rel.Min Celso de Mello, j.18.2.97; HC 76.381-5-SP, Rel. Min Carlos Velloso, j. 16.6.98; HC87.662-PE, Rel. Min Carlos Britto. J.5.9.06).

Nesse sentido ainda:

"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualifica-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, poder dever de ofício, da repressão penal - O depoimento testemunhal do agente policial somente perderá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar- tal como ocorre com as demais testemunhas- que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência" (HC 73.518-5 SP, Rel. Min. Celso de Mello, j.26.3.96). Além de toda a prova oral colhida, idônea a fundamentar o decreto condenatório, temos as declarações do acusado obtidas em juízo, oportunidade em que reconhece que estava na posse do entorpecente mas não como mencionado pelos policiais. Com efeito, o acusado teve a intenção de alterar sua conduta típica, reconheceu que estava com apenas 10 (dez) cigarros de maconha e não com 33 (trinta e três), como constou na apreensão. Disse ser usuário e que comprou o entorpecente para uso próprio. Declarou que estava ali para comprar uns fones de ouvido e que depois seguiria para a casa de sue tio, que mora no interior de São Paulo, vejamos: Johathan declarou que tem 21 anos de idade e trabalha no telemarketing. Nunca foi processado anteriormente. Mora sozinho em casa alugada. Não tem filhos. Reconhece que o entorpecente foi encontrado consigo, era para uso. Comprou entorpecente para o seu uso. Não havia 33 cigarros de maconha. Ia a Santa Efigênia porque pretendia comprar uns fones de ouvido para usar. Tinha 40 ou 50 reais consigo. O dinheiro não foi apreendido pelos policiais. Nessa época fazia bico de pinturas. Ia para a casa de um tio, residente em São Roque, irmão da sua mãe. É usuário de maconha mas não usa mais. Nunca teve passagens pela Vara da Infância. Comprou o entorpecente na rua Pagé. Disse aos policiais que o entorpecente era para uso próprio. Não sabe de onde apareceram os demais cigarros. Não conhecia os policiais antes dos fatos. Não foi ouvido na delegacia.

Pois bem.

Sua versão não tem sentido algum e não há um indicio sequer de que seja verdadeira. Ao contrario, vejamos.

Não provou que na época tinha um tio residente no interior de São Paulo e que para lá estaria se dirigindo. Não explicou porque comprou tanto entorpecente e depois ficou transitando pelo centro da cidade na posse da droga. O raciocínio seria ao contrario, ou seja, caso sua versão fosse verdadeira o entorpecente deveria ser a ultima coisa a ser adquirida pelo acusado, justamente após fazer as compras que pretendia no local onde se encontrava.

De outra partes, não havia qualquer situação antecedente entre o acusado e os policiais que o prenderam. Ao contrario, fica claro que nenhum dos dois estava na intenção de prejudicar o acusado, apenas fizeram seu trabalho.

E não é só.

A fotografia de fls. 22 bem comprova que toda a droga estava embalada de forma bastante similar motivo pelo qual é inviável se admitir que os policiais forjaram, em poder co acusado, 23 cigarros de maconha embalados de forma idêntica aos que haviam sido com ele apreendido.

Por fim, o acusado declarou que estava na posse de cerca de 40 ou 50 reais e que os policiais não apreenderam esse dinheiro, que permaneceu na posse do acusado. Tal fato não é verdade porque evidentemente, se estivesse na posse do dinheiro,

este teria sido apreendido até mesmo para reforçar a acusação de traficância. Daí porque, confrontados os elementos de prova, afigura-se de rigor a condenação nos termos da denúncia.
Passo a dosar a pena:

Fixo a pena base no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Isto porque, a meu sentir, não há razões para que a pena base seja aumentada além do mínimo já que os tipos de entorpecente apreendidos em posse dele bem como a quantidade, não desbordam do que ordinariamente já está previsto no tipo penal.

Em segunda fase, nada a reconhecer uma vez que a pena restou fuxada em seu mínimo. Em terceira fase, nos termos das ponderações trazidas pelo Ministério Público, com as quais concordo, entendo que é o caso de aplicação do tráfico privilegiado, ou seja, a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. O réu é primário e não possui maus antecedentes, fls. 47. Não se pode presumir, de outra banda, que ele se dedicava à atividade criminosa de forma habitual ou, ainda, que integrasse organização criminosa. E, seguido-se esse entendimento, no caso em apreço, a carga redutora a ser aplicada, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, é a máxima, ou seja, 2/3.

Assim sendo, diminuo a pena anteriormente aplicada em 2/3 (dois terços), com o que a reprimenda privativa de liberdade resulta em 01 (ano) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras da pena, torno definitiva a sanção acima estabelecida. Fixo o regime aberto para início de cumprimento da pena pois entendo ser suficiente a, no caso concreto, coibir a prática delitiva.

Por fim, estabeleço o regime aberto para cumprimento da reprimenda. Isto porque, apesar de o art. 2º, §1º da Lei nº 8.072/90 determinar a fixação de regime inicial fechado para cumprimento do delito de tráfico de entorpecentes, por equipará-lo a hediondo, esta previsão não se aplica ao tráfico privilegiado. Como cediço, em decisão recente, o Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de que o delito de tráfico de drogas, quando há o reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não é equiparado a hediondo, nos termos da Lei nº 8.072/90, conforme se depreende do teor da seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida” (Habeas Corpus nº 118.533/MS - Tribunal Pleno - Rel. Min. Cármen Lúcia - j. 23.06.2016).

No mesmo sentido, os recentes Habeas Corpus nº 136.545, de relatoria do Min. Celso de Mello, j. 07.10.2016; nº 136.762, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, j. 06.10.2016; e Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 937.651, de relatoria do Min. Roberto Barroso, j. 09.09.2016.

Consequentemente, concedo o apelo em liberdade.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação e condeno JONATHAN KENNEDY SANTOS DE ARRUDA, RG: 38145183, nascido em 19/06/2000, natural de São Paulo - SP, filho de Andre Luis de Arruda e Cristiane Regina dos Santos Cardoso, como incurso nas sanções do art. 33, “caput” da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 01 (ano) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados no mínimo legal e corrigidos desde a data do fato.

Outrossim, não há que se falar em conversão da pena privativa de liberdade em pena

restritiva de direitos. Ainda que haja entendimento jurisprudencial em sentido contrário e mesmo que nos autos do Habeas Corpus nº 97.256, a expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” tenha sido incidentalmente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, sendo promulgada a Resolução nº 05/2012 pelo Senado Federal, mantenho meu entendimento no sentido da impossibilidade da referida conversão.

Com efeito, inviável a fixação de penas restritivas aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, em qualquer de suas modalidades, havendo ou não aplicação do redutor de pena previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, até porque a conversão das penas privativas de liberdade não é automática, devendo o Magistrado analisar os preceitos estabelecidos do Código Penal.

No presente caso, temos que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao réu, que claramente praticava o comércio de drogas é insuficiente para a prevenção e repressão do delito, sendo, portanto, sua concessão, vedada pelo art. 44, inciso III, e 77, II, ambos do Código Penal.

O réu praticou crime gravíssimo, sendo com ele apreendido drogas de alto potencial lesivo, droga esta capaz de atingir a um sem-número de usuários e viciados. Assim, pelas circunstâncias concretas do crime, não há indicação de que tal substituição ou seja suficiente ou recomendável.

Cumram-se as Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo.

Transitada em julgado, determino as providências: 1) Em observância ao item 22, “d”, do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD; 2) Lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c.c art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 3) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal;

Transitada esta em julgado tornem concluso para a designação de data para audiência admonitória.

Custas ex lege

Publicada em audiência.

São Paulo, 31 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA